Разъяснения № 11 Совета Адвокатской палаты г. Москвы по вопросам профессиональной этики адвоката

25 ноября 2023 г.

Об участии в уголовном судопроизводстве защитников по назначению

(разъяснение принято на заседании Совета Адвокатской палаты г. Москвы 18 января 2016 года)

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ Протоколом от 27.09.2013 №1 утвердил Решение, в п. 1 которого указал на недопустимость участия в уголовном судопроизводстве адвокатов, назначенных следственными органами и судами защитниками, в качестве дублёров, то есть, при наличии в деле адвокатов, осуществляющих защиту тех же лиц на основании заключённых ими соглашений. Этим же Решением (п. 2) Совет Федеральной палаты адвокатов РФ рекомендовал «предусмотреть в решениях советов [адвокатских палат] положение о том, что адвокат не вправе по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда принимать поручение на защиту лиц против их воли, если интересы этих лиц в уголовном судопроизводстве осуществляют адвокаты на основании заключённых соглашений».

В связи с этим, а также с учётом вопросов, возникающих в дисциплинарной практике и обращениях адвокатов, Совет Адвокатской палаты города Москвы разъясняет следующее.

1. Навязывание адвокатом подозреваемому, обвиняемому своей юридической помощи в качестве защитника недопустимо ни при каких обстоятельствах, в том числе и при осуществлении защиты по назначению. В равной мере недопустимым является такое навязывание и со стороны органов и лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, в отсутствие законных оснований для назначения защитника. Совет Адвокатской палаты города Москвы неоднократно разъяснял порядок и условия вступления адвоката в дело и осуществления им защиты по назначению, в том числе, в части, касающейся неукоснительного соблюдения права подозреваемого, обвиняемого на свободный выбор защитника, включая отказ от него, и о недопустимости какого бы то ни было, прямого или косвенного, содействия в ущемлении этого права со стороны адвокатов, назначенных защитниками (Разъяснения Совета: от 02.03.2004

«Об участии в делах по назначению», от 20.11.2007 «Об основаниях прекращения участия в уголовном деле адвокатов-защитников по соглашению», от 24.09.2015 «О соблюдении требований части 3 и части 4 статьи 50 УПК РФ при осуществлении защиты по назначению»). Эти разъяснения продолжают действовать в полном объёме и подлежат безусловному исполнению адвокатами в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката.

2. Исходя из указанных разъяснений, основанных, в том числе, на тех же требованиях Конституции РФ и законодательства РФ, правовых позициях Конституционного Суда РФ, которые приведены в Решении Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 27.09.2013, Совет Адвокатской палаты города Москвы считает недопустимым осуществление адвокатами защиты по назначению наряду с адвокатами, осуществляющими защиту тех же лиц на основании соглашения, за исключением случая, указанного в п. 3 настоящих Разъяснений. Во всех прочих случаях защитник по назначению не вправе принимать участие (в том числе, продолжать ранее начатое им участие) в дознании, предварительном следствии либо в рассмотрении дела судом при наличии у подозреваемого, обвиняемого защитника по соглашению, от которого он не отказался и который не отведён от участия в деле в порядке и на основаниях, предусмотренных законом. Адвокат, назначенный защитником и установивший факт наличия у того же лица защитника по соглашению, обязан незамедлительно предпринять все предусмотренные законом и вышеуказанными разъяснениями Совета Адвокатской палаты гор. Москвы действия, направленные на прекращение своего участия в деле, включая (но не ограничиваясь этим) поддержку заявления подозреваемого, обвиняемого об отказе от него, собственное аналогичное заявление и проявление настойчивости с целью надлежащего рассмотрения и разрешения этих заявлений дознавателем, следователем или судом, а при их отказе или уклонении от принятия такого решения адвокат должен покинуть место процессуальных действий, сделав соответствующие заявления. Совет Адвокатской палаты города Москвы подчёркивает, что такие действия защитника по назначению не могут расцениваться как отказ от защиты и являются не только правомерными, но и обязательными. Это требование распространяется и на случаи, когда в дело, в котором уже участвует защитник по назначению, впоследствии вступает защитник того же лица по соглашению.

3. Защитнику по назначению, отказ от которого, заявленный в установленном законом порядке, не принят дознавателем, следователем или судом с вынесением соответствующего процессуального решения, при определении своей дальнейшей позиции следует исходить из следующего. В соответствии с ч. 2 ст. 52 УПК РФ, отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда. Вместе с тем, само по себе наличие у указанных субъектов уголовного судопроизводства права не принять отказ от защитника не означает, что они могут пользоваться этим правом произвольно либо в целях, не соответствующих конституционным требованиям и назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). В соответствии с требованиями ст.ст. 11, 16, 243 УПК РФ, именно на орган или должностное лицо, осуществляющие от имени государства производство по уголовному делу, возложена

обязанность обеспечить всем участникам судопроизводства реализацию их прав и законных интересов. Пленум Верховного Суда РФ в п. 18 Постановления от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» указал, что «Суд может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации отдельных правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно недобросовестным использованием ими этих правомочий в ущерб интересам других участников процесса, поскольку в силу требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц». Указанное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ о недопустимости злоупотреблений правом на защиту, однако, ни в коей мере не означает, что другие участники судопроизводства, и в особенности те из них, которые осуществляют властные полномочия, могут злоупотреблять ими, тем более – путём ущемления конституционного права на защиту. При этом, в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 7 УПК РФ, определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Основываясь на этих требованиях закона и правовых позициях высших судов РФ, Европейского Суда по правам человека в их системном истолковании, Совет Адвокатской палаты города Москвы считает, что отказ от защитника по назначению при наличии у того же лица защитника по соглашению может быть не принят дознавателем, следователем или судом лишь в том случае, когда процессуальное поведение защитника по соглашению, либо поведение подозреваемого, обвиняемого при реализации права на свободный выбор защитника, будучи явно недобросовестным, ущемляет конституционные права других участников судопроизводства. Иными словами, непринятие отказа от защитника по назначению при наличии защитника по соглашению может являться законным и обоснованным лишь в том случае, когда действия или бездействие подозреваемого, обвиняемого при реализации права на свободный выбор защитника и/или действие или бездействие защитника по соглашению противоречат требованиям закона либо представляют собой злоупотребление правом на защиту, и такое нарушение или злоупотребление дезорганизует ход дознания, предварительного следствия либо судебного заседания, то есть, направлено на срыв судебного процесса либо досудебного производства по делу. Следовательно, продолжение участия в деле защитника по назначению при наличии у того же лица защитника по соглашению не может рассматриваться как недопустимое дублирование функций защиты, нарушающее конституционное право подозреваемого, обвиняемого на свободный выбор защитника, только при условии, что процессуальное решение дознавателя, следователя или суда, которым отклонён заявленный отказ от защитника по назначению, не только вынесено в соответствии с требованиями закона, но и содержит указание именно на такое поведение подозреваемого, обвиняемого и/или защитника (защитников) по соглашению, с приведением конкретных фактических обстоятельств, подтверждающих обоснованность этого вывода. Процессуальное решение органа или лица, осуществляющего производство по уголовному делу, которым отклонён заявленный отказ от защитника по назначению, не содержащее такого обоснования, а принятое лишь со ссылкой на наличие дискреционного полномочия, предусмотренного ч. 2 ст. 52 УПК РФ, не может, как явно не соответствующее

требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, являться законным и достаточным основанием продолжения участия в деле защитника по назначению, дублирующего защитника по соглашению, и вынуждает защитника по назначению устраниться от участия в деле в соответствии с п. 2 настоящих Разъяснений.

Настоящее Разъяснение подлежит безусловному исполнению адвокатами в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката. Их несоблюдение или ненадлежащее соблюдение влечёт применение к адвокату мер дисциплинарной ответственности, вплоть до прекращения статуса адвоката, за нарушение требований пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8, п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката. При этом Совет Адвокатской палаты города Москвы обращает внимание, что, в соответствии с ч. 3 ст. 18 указанного Кодекса, адвокат, действовавший в соответствии с разъяснениями Совета относительно применения положений Кодекса, не может быть привлечён к дисциплинарной ответственности.